

1501960-29.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... estavam em poder dela para a realização do tráfico, não tendo nenhuma responsabilidade pela mercancia. Aduziu que consegue ficar sem usar drogas e que de fato foi detido depois de obter a liberdade também por uma acusação de tráfico. Não soube justificar o teor completamente divergente do interrogatório policial, negando ter mentido naquela ocasião.

Bianca negou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501960-29.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501960-29.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204623/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 19316611 - 04º D.P. GUARULHOS, 3636/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2204623 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

BIANCA DA SILVA ANNUNCIATO ROCHA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Vistos.

BIANCA DA SILVA ANNUNCIATO ROCHA e RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, porque,

no dia 29 de julho de 2021, por volta das 13h30, na Estrada do Sacramento, altura do nº 1500, Bairro Pimentas, nesta comarca de Guarulhos, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, portanto em concurso de agentes, traziam consigo e guardavam, ao todo e para fins de tráfico, 113 eppendorfs contendo 36,9g de cocaína e 52 porções contendo 149,5g de Cannabis Sativa L, droga conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida. Os réus foram notificados (fls. 109 e 134) e apresentaram resposta à acusação (fls. 143/144). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 167/168).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e os acusados foram interrogados (fls. 221/222 e 223/224).

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, requereu o aumento da pena na primeira fase, devido à quantidade de drogas e, na terceira, com relação ao réu Rafael, rejeição do redutor do privilégio, pois, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, logo voltou a praticar o crime de tráfico de drogas. Com relação ao regime, manifestou-se pela possibilidade de aplicação o regime aberto para a ré, com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, admitindo, para o acusado Rafael, regime semiaberto, mas sem substituição.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, e, subsidiariamente, com relação a Rafael, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea apresentada em sede policial, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a adoção do regime aberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com relação a Bianca, pediu a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; adoção do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 19/23), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 210/212; 213/125) e pela prova oral colhida.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu Rafael negou vagamente a prática delitiva. Apresentou versão contraditória, alegando, inicialmente que tinha as drogas, ao todo dez porções, a fim de vender para "comprar pão para as crianças". Posteriormente, disse que estava com poucas porções de cocaína e maconha apenas para seu uso próprio, adquiridas da corre, a qual era sua ex-namorada à época. Destacou que as outras porções estavam em poder dela para a realização do tráfico, não tendo nenhuma responsabilidade pela

mercancia. Aduziu que consegue ficar sem usar drogas e que de fato foi detido depois de obter a liberdade também por uma acusação de tráfico. Não soube justificar o teor completamente divergente do interrogatório policial, negando ter mentido naquela ocasião.

Bianca negou que estivesse no tráfico, mas admitiu que sabia que Rafael, com quem ficava, estava traficando. Aduziu que, quando os policiais chegaram, ele acabou admitindo confessando o delito e dizendo onde estava a droga, ou seja, sob um pneu. Asseverou que então a fizeram levá-los até onde estavam guardados os entorpecentes. Ressaltou que é usuária de maconha, mas não dependente. Destacou que está trabalhando e que tem endereço fixo.

As versões vagas, contraditórias, isoladas e inverossímeis acabaram refutadas pelas provas colhidas.

O policial Alex Sandro afirmou que passavam pelo local, quando o casal se sentiu incomodado e reagiu de forma suspeita. Fizeram a abordagem e localizaram uma sacola ao lado de Rafael. Indagado, ele admitiu que estava com drogas, isentando Bianca da participação no tráfico. Esta, contudo, diante das indagações sobre a existência de mais entorpecentes, acabou indicando um lugar do outro lado da rua, onde localizaram mais entorpecentes idênticos. Não os conhecia.

O policial André confirmou que seu colega Alex percebeu a situação suspeita do casal e pararam a viatura adiante, retornando a pé para a abordagem, sem despertarem suspeita. Aduziu que o réu, ao ser abordado, admitiu que havia drogas na sacola ao seu lado e que estava no tráfico, isentando Bianca. Esta, contudo, ao ser indagada pelos policiais, indicou onde estaria o restante da droga, em condições idênticas. Ambos os policiais destacaram que os réus seriam companheiros, segundo suas próprias informações.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. Na data aludida, os acusados foram surpreendidos juntos no meio do canteiro central da Estrada do Sacramento com uma sacola ao lado, repleta de drogas. Indagados, Rafael admitiu que estavam na mercancia para isentar Bianca. Essa, todavia, foi quem indicou outra sacola com entorpecentes a trinta metros do local, revelando ciência e adesão à atividade. Conduzidos à delegacia e interrogados formalmente, Bianca permaneceu em silêncio e Rafael confessou a traficância, pontuando, no entanto que sua companheira não estava envolvida (fls. 10 e 11). Em juízo, tentou em vão se retratar, com narrativa desprovida de sentido lógico, coerência e suporte indiciário mínimo. Não há como compreender naquela situação finalidade diversa da venda e presumir abuso de autoridade e falsos testemunhos dos policiais, inclusive sobre a confissão e revelação do local de ocultação do restante do entorpecente pelos próprios réus.

Outrossim, no caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelos réus em situação de comércio, as confissões e entrega do restante escondido em outro lugar, denotando plena adesão de ambos ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para serem incriminados falsamente.

Não é crível, outrossim, que a grande quantidade de maconha e cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público. A alegação vaga, isolada e ulterior de Rafael foi rebatida pelas evidências do dolo e da autoria desse crime. Não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre o liame subjetivo dos dois com as drogas e confissões. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório

determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente em palavra de policial ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

De outro giro, observa-se que as versões dos acusados são contraditórias e inconsistentes. Em sede policial Rafael buscava isentar Bianca da responsabilidade criminal, ao passo que em juízo lhe imputou a autoria exclusiva do tráfico de drogas, dizendo-se inocente e apenas usuário. No mais, em que pese a alegação ulterior apresentada, conclui-se do conjunto probatório que Rafael confessou prontamente a prática delitiva e tinha ciência de que as outras porções estavam com Bianca para a realização do tráfico, tendo declarado espontaneamente tal fato para

os policiais. Bianca, por sua vez, levou-os até o ponto de ocultação e não negou envolvimento ou apresentou justificativa para estar com o companheiro naquela situação e mercancia. As testemunhas, à míngua de provas de suspeição, não inventariam e mentiriam sobre tal dinâmica do flagrante. Não é crível, ademais, que o acusado, sendo companheiro de Bianca, iria ao local dos fatos para adquirir dela porções de entorpecentes e permaneceria ao seu lado, sem escopo de auxiliá-la, ciente do risco de ser preso.

No mesmo sentido, a versão apresentada pela acusada Bianca restou completamente isolada nos autos. Em juízo atribuiu a responsabilidade exclusiva do tráfico de drogas ao acusado Rafael, mas os policiais confirmaram que foi ela quem os levou até as demais porções de drogas apreendidas. Assim, ela tinha ciência dos detalhes do esquema de vendas e somente a adesão ao delito explica sua presença no local, ao invés da saída imediata após a suposta compra para uso.

Nesse sentido, os relatos dos policiais devem prevalecer sobre a fantasiosa narrativa dos réus, ávidos pela improcedência da ação. Os depoimentos foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente dois desconhecidos. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. Os acusados são imputáveis e praticaram os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre os réus e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal ante as primariedades. A quantidade e tipo de entorpecente não destoam do normal em empreitadas desse jaez, sendo já determinante na configuração do próprio tipo penal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Não há como se reconhecer a confissão do acusado, porque apenas apresentada em sede policial e rechaçada em juízo.

Na terceira fase, com relação a Rafael, após ser preso e beneficiado com a liberdade provisória, logo voltou a praticar o crime de tráfico de drogas e foi preso novamente em flagrante. Assim, há evidência segura da dedicação habitual do acusado a atividades criminosas, justificando, pela reiteração específica de tal conduta em curto espaço de tempo (cerca de um mês apenas), o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Por outro lado, com relação a Bianca, em razão dos bons antecedentes e da ausência de provas de dedicação à atividade criminosa, incide a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3 da pena, resultando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 333 dias-multa.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não obstam a redução e não ensejam, com certeza, a conclusão de que a agente se dedicava à atividade criminosa, sobretudo por ocasião de mero flagrante da posse. Dos dados pontuais, exclusivamente, não se extrai filiação a grupo criminoso ou mesmo envolvimento permanente com atividade ilícita, sobretudo organizada. Embora comum nestes casos, seria necessário elemento concreto convincente a respeito do vínculo, já que o termo legal "dedicação" pressupõe alguma habitualidade. As investigações, contudo, não se seguiram, de maneira frutífera, sobre o liame e a estabilidade, subsistindo a hipótese de que se tratava de empreitada de "primeira viagem", como o ocorre, por exemplo, quando alguém faz um único transporte de grande quantidade de drogas. Além disso, não se apreendeu instrumento, proveito ou vestígio, como contabilidade, do exercício contínuo de tal atividade ilegal. Enfim, sequer foi obtida, outrossim, sob o crivo do contraditório, prova da condição de integrante de grupo especializado ou de encargo duradouro e relevante em tal atividade.

Assim, reconhecido o "privilégio" para Bianca, considerando a quantidade e espécie de parte do entorpecente (cocaína), mais lesiva à saúde do que outras, de um lado, e a função de pequeno varejo, de outro, a reprimenda é reduzida no patamar intermediário, perfazendo 3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-multa. À mingua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e natureza da droga, não cabe a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas "poderão" ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução - que pode ir além do mínimo legal - e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto, o grau de culpabilidade e especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva e danos à saúde destes. Assim, nega-se a diminuição máxima ante a quantidade de cocaína. Em contrapartida, a função desempenhada (varejo e não gerência) e as condições subjetivas aparentes não se coadunam com a redução mínima. Não havendo mais causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado.

No tocante ao regime inicial de pena, com relação a Rafael, a gravidade do crime e a quantidade da pena, superior a 4 anos, impõem o regime inicial semiaberto, estando, ainda, legalmente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A quantidade, vale dizer, já obsta a reprimenda alternativa e regime aberto, além de não ser a substituição por pena alternativa socialmente recomendável. Em razão da primariedade e da pena, contudo, deixo de adotar o regime fechado.

A despeito da compreensível necessidade de tempo para outorga da prestação jurisdicional de primeira instância, não é possível conceber regime aberto, mediante estimativa da detração. Além de destoar da quantidade e dos fundamentos da pena, a aplicação de regime mais brando, sem correspondência com a disciplina legal da dosimetria, mas com base na duração da prisão provisória, é desprovida de comprovação, por ora, de todos requisitos. A custódia pode ter sido computada também a outro título, pois pode ter tido a prisão decretada ou a execução de condenação iniciada por outro delito. Não é certo que o tempo de prisão provisória seja suficiente para alteração imediata do regime perante o quantum da pena ora estabelecido, além de ausente verificação das condições subjetivas do sentenciado, mormente comportamento carcerário. Por conseguinte, a imediata mudança de regime não atenderia aos princípios da individualização da pena e da isonomia substancial.

Por outro lado, com relação a Bianca, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade da pena, a natureza do crime (sem violência ou ameaça) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. A despeito da gravidade do delito, cumpre atentar para a importância da primeira oportunidade de ressocialização em liberdade, nessa espécie de infração. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTA TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

“EMENTA PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade. Provas dos autos que evidenciam a autoria e materialidade delitivas de forma robusta. Confissão judicial e palavras dos PMs. Condenação mantida. Possibilidade de redução das penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio aplicável aos réus, primários. Redutor na fração de um quinto, considerada a quantidade de entorpecente apreendida. Regime inicial intermediário suficiente para a reprovabilidade do delito. Apelos providos em parte para redução das penas. (TJ/SP,Apelação.º0001273-25.2018.8.26.0635;16ªCâmarade Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/08/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.CONDENACÃO.DOSIMETRIA.PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DASDROGAS APREENDIDAS.ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.PACIENTE RAFAEL.QUANTIDADE E NATUREZA DASDROGAS. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DAPENA-BASE E PARA A NEGATIVA DE APLICAÇÃODA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.BIS INIDEM.OCORRÊNCIA.ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO,DE OFÍCIO” (STJ, Habeas Corpus nº 317.461-SP, SextaTurma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,julgado em 26.05.2015).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação

art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

No mesmo diapasão, preenchidos ainda os requisitos do art. 44, do CP, à luz da primariedade e da pena aplicada, e sendo socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO, qualificado nos autos, no cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/2006 e a acusada BIANCA DA SILVA ANNUNCIATO ROCHA no cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação gratuita de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução, além do pagamento de 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

O réu Rafael não poderá recorrer desta sentença em liberdade, já que permaneceu preso até a presente decisão, sendo contraproducente sua soltura, neste lance, em detrimento da aplicação da lei penal, após imposição de regime não aberto. Ademais, a gravidade do delito, mormente pela presença de cocaína, que coloca em risco o meio social e fomenta outros crimes, e as condições subjetivas do réu, que frustrou benefício anterior, tornam necessária a custódia como garantia da ordem pública. O réu apenas deve retornar ao convívio social, quando concluído o processo de ressocialização, pois não honrou a oportunidade obtida anteriormente, ao ser beneficiado pela liberdade provisória (fls. 65/69), e retornou rapidamente ao tráfico. Recomende-se o acusado no ergástulo onde se encontra.

A ré Bianca poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelos sentenciados, deferida a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 09 de maio de 2022.

Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA